

1500254-33.2022.8.26.0484

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, assim como WELINGTON também é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico. WELINGTON foi preso em flagrante, contudo, quando estava sendo encaminhado ao Juízo da Comarca para fins de audiência de custódia, ele fugiu. Por fim, teve a prisão preventiva decretada. A quantidade, natureza e forma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

1ª Vara Judicial

Av. Rio Grande, 730, Promissao - SP - cep 16370-000

1500254-33.2022.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500254-33.2022.8.26.0484

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Jofer Lopes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Vistos.

Wellington Jofer Lopes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia) por, nos termos da denúncia: (...) no dia 28 de abril de 2022, por volta das 11h30min, na Rua das Andorinhas, 425, trazer consigo, guardar e manter em depósito drogas consistentes em: 106 (cento e seis) invólucros plásticos, contendo em seu interior maconha, com peso líquido total de 108,56 gramas e 181 (cento e oitenta e um) invólucros plásticos, contendo em seu interior "crack", com peso líquido total de 37,19 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...) por ocasião dos fatos, em operação contra o tráfico de drogas, realizado pela polícia militar juntamente com o BAEP, foram abordadas três pessoas, sendo WELINGTON, a namorada dele chamada Isabela e um terceiro chamado Gilberto. Ocorre que, efetuada revista pessoal, foi encontrado em poder de WELINGTON uma tira com cinco porções de "crack" e também a quantia de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), que, indagado sobre o dinheiro, não soube informar a quantia que tinha. Efetuadas buscas em local bem próximo aonde estava sentado o denunciado, com apoio do canil, foram encontradas, em três pontos distintos, mais drogas, sendo "maconha e crack", as quais eram idênticas as tiras de drogas encontradas em poder de WELINGTON. É dos autos que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, assim como WELINGTON também é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico. WELINGTON foi preso em flagrante, contudo, quando

estava sendo encaminhado ao Juízo da Comarca para fins de audiência de custódia, ele fugiu. Por fim, teve a prisão preventiva decretada. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos com o denunciado (individualmente embalados e prontos para a venda); os demais entorpecentes encontrados em local bem próximo ao local este estava sentado o denunciado, o local dos fatos, as informações de traficância pelo acusado, o dinheiro apreendido, as circunstâncias da prisão e fuga, indicam que WELLINGTON trazia consigo, guardava e mantinha em depósito as drogas para entregá-las ao consumo de terceiros".

O réu foi preso em flagrante em 28 de abril de 2022, de acordo com o auto de prisão em flagrante de fls. 1/2.

Conforme noticiado no boletim de ocorrência nº BH8917-2/2022 (fls. 56/57), em síntese, após a Autoridade Policial finalizar todas as peças do Auto de Prisão em Flagrante Delito originado do Boletim de Ocorrência nº BH6181-1/2022 - 1ª Edição, quando Wellington estava sendo encaminhado ao Juízo da Comarca para fins de audiência de custódia, durante o procedimento de colocação do capturado na viatura policial para transporte até a CPJ LINS, ele empreendeu fuga, mesmo estando devidamente algemado.

A decisão de fls. 76/77 decretou a prisão preventiva do acusado.

A denúncia foi oferecida (fls. 88/90).

O pedido de busca e apreensão criminal nº 1500263-92.2022.8.26.0484 foi apensado a estes autos (fls. 94).

Às fls. 115/116 foram prestadas as informações referentes ao Habeas Corpus nº 2098747-82.2022.8.26.0000.

A decisão fls. 124/125 determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar.

O acusado não foi notificado pessoalmente, porém constituiu defensoras nos autos (fls. 93), que ofereceram defesa prévia às fls. 130/147.

Laudos periciais juntados às fls. 157/162, fls. 163/167 e fls. 168/170.

À fl. 173, a defesa arrolou em complemento, outras três testemunhas que estariam presentes no local e hora dos fatos descritos na denúncia.

O Ministério Público se manifestou às fls. 176/179.

A decisão de fls. 182/184 afastou a preliminar de rejeição da peça acusatória, indeferiu o pedido de liberdade provisória, deferiu a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 173, recebeu a denúncia, determinou a citação do acusado e designou audiência de instrução e julgamento. Por fim, indeferiu os pedidos formulados pela defesa no item "f" de fls. 147, devendo ser aguardada a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o pedido poderá ser reiterado.

O acusado não foi encontrado para citação (fls. 221/222).

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização do atual endereço do réu, foi determinada a sua notificação e citação editalícia, com o prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361, do Código de Processo Penal, acerca da denúncia.

A decisão de fls. 248 cumpriu o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e manteve a prisão preventiva do acusado.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas da acusação PM Diego Felício Novaes, PM Ricardo Alexandre Neves Correa, Sebastião Soares da Silva e Rafael Fernando Kondo Kamiji, a testemunha comum ISABELA VITÓRIA GARCIA DE LIMA e as testemunhas arroladas pela defesa, Wevelyn Lopes da Silva e Cristina da Paz Lopes, sendo o réu interrogado ao final.

Foram feitos requerimentos defensivos na audiência, quais sejam: 1) acesso aos autos de busca e apreensão do réu (no total de 03), cujos números não estando disponíveis neste ato, pediu a defesa, prazo para juntada para enumerá-los; 2) Gravação da câmera da Delegacia de Polícia do dia da prisão e fuga do réu e 3) Revogação do mandado de prisão preventiva do réu. O Ministério Público se manifestou acerca dos pleitos em audiência, favoravelmente aos primeiro e desfavoravelmente ao segundo e ao terceiro.

Decisão de fls. 255/256 esclareceu que nos autos só consta um apenso, deferindo acesso à defesa a este apenso. Quanto aos demais, somente seria possível a liberação de acesso se fornecidos os números dos autos pela parte. Quanto aos

demaís pleitos, estes foram indeferidos pelas razões lá expostas.

O Ministério Público, em memoriais (fls. 267/281), pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia. Requer que uma das condenações transitadas em julgado contra o réu seja valorada na primeira fase da dosimetria e, outra, na segunda. Na primeira fase, ainda, requer que seja aumentada a pena porque um dos entorpecentes era o crack.

A defesa peticionou explicando que não foi habilitada nos autos em que deferidos atos de busca e apreensão (fls. 282/284), sendo reiterada a determinação de concessão de acesso (fl. 285).

Auto de incineração dos entorpecentes (fls. 291/293).

Então, a defesa do acusado em memoriais, clamou pela absolvição em relação ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não há provas suficientes esclarecendo que houve quebra na cadeia de custódia pelo fato de os entorpecentes encontrados na posse do acusado não terem sido mantidos separados dos entorpecentes encontrados nas proximidades. Ressalta, ademais, que os demais elementos de prova são insuficientes para a condenação e tece questões acerca da forma pela qual foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, argumentando que o aparelho celular da genitora do acusado teria sido levado pela polícia quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não constando nos autos auto de apreensão deste bem.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem. De se ressaltar, desde logo, que muito embora o réu não tenha sido citado pessoalmente, está foragido desde a tentativa de prisão em flagrante e constituiu advogado desde o início da investigação, o que demonstra sua plena ciência acerca do processo, tendo optado, contudo, por não comparecer aos atos processuais.

Ora, consoante preceitua o artigo 570 do Código de Processo Penal, o comparecimento espontâneo do réu em Juízo sana eventual vício decorrente de ausência de citação, tanto mais quando como no caso dos autos -, ele comparece devidamente representado por Defensor constituído. A propósito, já reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC21506/MS, em 05.02.2007, que “Não há falar em nulidade do feito por vício da citação editalícia, se o réu compareceu ao processo, em momento oportuno, representado por advogado constituído, que apresentou regularmente defesa prévia, arrolou testemunhas, requereu diligências no curso do processo, atuou em toda a produção da prova e ofertou suas alegações finais”.

No mesmo sentido:

A constituição e intervenção do defensor do acusado, com atuação no processo depois de ordenada, mas antes de realizada a citação, sana eventual vício relacionado à integração do réu à Ação penal. Inteligência do art. 570 do CPP. Precedente do STJ. (HC 202571-RJ, 5ª T., rel. Marco Aurélio Bellizze, 28/02/2012, v.u.).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. ACUSADO CITADO POR EDITAL. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RENÚNCIA DOS PODERES 3 (TRÊS) MESES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A teor do art. 366 do CPP, a suspensão do processo penal e do prazo prescricional, somente é possível quando o acusado, após citado por edital, não comparece e não constitui advogado nos autos.

3. No caso, embora o paciente tenha sido citado por edital, constituiu, desde a fase inquisitorial, advogado nos autos com amplos poderes, o que demonstra que

conhecia da imputação contra ele dirigida.

4. A renúncia do advogado deu-se 3 (três) meses após o recebimento da denúncia, inexistindo ilegalidade na decisão do Juízo de primeiro grau que determinou o prosseguimento do feito com a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado, uma vez que não seria possível intimá-lo pessoalmente para constituir defensor de sua confiança, tendo em vista encontrar-se em lugar incerto e não sabido. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 338.540/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a análise da prova oral produzida.

O policial militar Diego Felício Novaes, testemunha da acusação, em juízo, disse que estavam em uma operação conjunta e se deslocaram até o local que é conhecido por ser local em que ocorre tráfico de drogas. Viram postura suspeita de algumas pessoas, dentre elas o acusado, com quem foi encontrada quantia em dinheiro e crack. Com as outras pessoas nada foi encontrado. Fizeram buscas nas proximidades e encontraram mais drogas, então, levaram o acusado preso em flagrante. Ele é conhecido nos meios policiais por conta de tráfico de drogas. Esses entorpecentes encontrados nas proximidades tinham a mesma embalagem das que foram encontradas com ele. Não havia outras pessoas na proximidade que pudessem ser relacionadas à droga. Não soube explicar a origem do valor. Os policiais, de posse das drogas, conduziram todas à delegacia e o invólucro ficou com a polícia civil. As que foram encontradas em posse do acusado e no local foram levadas separadas. As drogas foram encontradas ao longo da via, em uma área de mata, dentro do matagal. Foi encontrada pelo cachorro. Em três locais que foram encontradas drogas, dois locais no matagal e um em uma casa abandonada.

O policial militar Ricardo Alexandre Neves Correa, testemunha da acusação, em juízo, disse que estavam em operação juntamente com o pessoal do canil. Foram ao Município de Promissão a um local conhecido pelo tráfico de drogas. É um local de chão batido, de difícil acesso, motivo pelo qual as pessoas conseguem se evadir com facilidade. Havia dois homens e uma menina, um homem estava completamente bêbado e o outro era o acusado. Com ele foi encontrado celular, quantia em dinheiro e crack. Ele disse que só usava maconha. Foram encontradas drogas no Ele negou que estava com as outras drogas que foram encontradas pelo cão. O depoente não conhecia o acusado, mas policiais de lá tinham passado bastante informação sobre ele, sobre tráfico naquela região. O depoente realizou a busca pessoal no acusado. De imediato ele indicou ao tenente Diego que encontrou o entorpecente e depois passaram as drogas para a polícia civil.

A testemunha da acusação Sebastião Soares da Silva, em juízo, narrou que soube da prisão do acusado, ele estava lá. O depoente viu a viatura lá na região, o acusado estava com a namorada, aí um grupo de policiais abordou o acusado e outros foram mais para baixo, em um mato que tem ali. E ficou um policial com ele, com a namorada e o Pedrinho. Ele não viu os policiais voltarem com alguma coisa. Conhece o depoente faz muito tempo. O depoente é pintor. Não é envolvido com drogas. O depoente viu o acusado ser revistado. Quando ele viu o acusado ser revistado não viu nada ser encontrado com ele.

A testemunha da acusação Rafael Fernando Kondo Kamiji, em juízo, disse que o acusado foi preso pela força tática à polícia civil. A força tática apresentou grande quantidade de droga. O acusado é conhecido nos meios policiais como realizador de tráfico. Soube que o acusado fugiu quando da prisão. O depoente não participou do flagrante, ele estava na delegacia. O depoente viu a droga ser entregue na delegacia. Não se recorda se a droga estava toda junta ou não, mas eles apresentaram a droga toda de uma vez. Na hora da fuga, quando ele estava sendo levado para a audiência de custódia, era o depoente que o estava levando. No momento em que eles estavam removendo o acusado, como é necessário fazer isso no

lado de fora, no momento que ele viu a porta ele deu um forte empurrão no depoente e conseguiu fugir. Saíram no encalço dele, mas ele entrou em uma mata fechada, e não conseguiram entrar. Ele agrediu o depoente com um empurrão bem forte. A investigadora Valéria que estava com ele. Há câmeras na parte de fora da delegacia. A testemunha de defesa Fabiana Pina Moreno, em juízo, mencionou que somente fez buscas na namorada do acusado, com ela nada foi encontrado. Ela fez a revista e foi embora. No período em que ela estava lá já havia sido encontrada droga, tanto que o acusado já estava algemado. Ela não participou de outras buscas. É policial de Promissão mesmo. A depoente disse que não fez nenhuma busca na área.

A testemunha de defesa Anderson Aparecido Santos Tavares, em juízo, disse que no dia dos fatos, chegou depois. A colega de farda dele fez busca pessoal na namorada do acusado. O depoente somente ficou no local o mesmo tempo que a PM Fabiana estava no local. Depois disso, saíram do local. Enquanto ele estava ali, já tinham encontrado drogas com o acusado, mas não sabia se a equipe do canil já tinha encontrado algo. Ninguém perguntou nenhuma orientação ao depoente. O depoente não estava na delegacia quando as drogas foram entregues. O acusado é conhecido nos meios policiais, outra equipe de força tática já havia prendido ele por tráfico também. O local em que ele reside é conhecido pelo tráfico de drogas.

A testemunha de defesa Alexandre Macedo, em juízo, informou que estava junto com a Fabiana e com o Tavares quando da abordagem do acusado. Quando ele chegou lá ele imagina que já tinham encontrado alguma droga porque o acusado já estava detido. Não lembra se o acusado estava algemado. O depoente é policial em Promissão, já conhecia o acusado de outras denúncias. Já tinha realizado buscas com ele. O bairro é conhecido pela venda de drogas.

A testemunha comum Isabela Vitória Garcia de Lima, em juízo, mencionou que estavam indo almoçar na casa da sogra dela. Quando eles passaram, o Gil pediu dois reais para eles, nisso o acusado foi entregar os dois reais para ele, quando chegaram os policiais enquadrando eles. Nisso fizeram a revista no acusado. Não acharam nada. Deixaram dois policiais com ele. Ele morava ali onde foi realizada a busca pessoal.

A testemunha da defesa Wevelyn Lopes da Silva, irmã do acusado, motivo pelo qual não teve que prestar o compromisso de dizer a verdade, em juízo, narrou que estavam na frente de casa quando viram o acusado vindo com a mulher dele. Nisso viram o Bebinho ir falar com ele. Nisso a polícia chegou e começou a revistar o acusado. Nisso a depoente foi chegar perto os policiais disseram para ela não chegar perto. Ele não fugiu porque sabia que não tinha nada a ver. Nisso chegou a policial feminina chegou e levou a namorada do acusado dentro de uma casa que tem ali perto e fez ela tirar toda a roupa. Outro grupo de policiais desceu e sumiram.

Perguntaram se já podia soltar o acusado, nisso o Tavares disse que não podia.

Nisso a depoente disse que ligou o advogado. A depoente perguntou para o policial se tinham encontrado algo, ele disse que anda, mas que ele tinha que ficar ali.

Perguntaram para a policial feminina se podiam soltar ela e disseram que não.

Quando eles foram lá o delegado disse que ele ia ficar preso, a depoente disse que gravou a abordagem. O delegado perguntou o motivo pelo qual ela gravou, ela disse que porque eles já tinham feito isso. Depois disso, os policiais entraram na casa dela às seis e pouco da manhã e arrombaram o portão dela. E reviraram a casa dela e da mãe. Foram lá três vezes procurar ele. Disse que um homem de óculos inclusive a ameaçou falando que ela devia dizer onde estava o acusado. A região em que eles moram é conhecida por conta do tráfico de drogas.

A testemunha da defesa Cristina da Paz Lopes, mãe do acusado, motivo pelo qual não prestou compromisso, em juízo, narrou que no dia ele estava descendo com a mulher dele para ir para a casa da depoente para almoçar. Nisso o acusado foi falar com o bebinho, quando a polícia chegou e abordou o acusado. Então, um dos policiais perguntou se poderia liberar ele, outro disse que não. Uma policial militar levou a mulher do acusado para revistar, voltou e disse que não encontrou nada. Eles acharam que iam soltar ele. Um policial de outro lugar, não de Promissão, perguntou se já podiam liberar o acusado, e um policial disse que não. Perto da casa dela é cheia de mata, se ela pudesse ela se mudava. Ali é um local em que passa muita gente, é rua de terra, sempre tem movimento. Após a prisão do acusado foram realizadas algumas buscas na casa dele para encontrá-lo. Chegaram a ir duas vezes

no mesmo dia. Ela já tinha perdido o sossego, já tinha cansado. A polícia queria que ela e a filha dela dissessem onde estava o acusado, mas ela não sabia. Eles cortaram a corrente, o cadeado da casa dela, reviraram a casa dela. Levaram o celular da depoente e até hoje não soube de nenhum celular. Não foi apresentado mandado em nenhuma das ocasiões. O acusado estava sentado em cima das mãos durante a abordagem. A depoente não morava com o acusado. Nesse dia ele ia até a casa dela, porque ele estava com a cabeça machucada. Moravam só ele e a mulher. O acusado trabalha de pintor, mas neste dia ele estava desmontando uma varanda. Ele não tinha registro em carteira. Não sabe dizer se ele usava drogas, se usava, era escondido. Não tinha conhecimento de envolvimento dele com drogas. Já é a segunda vez que isso acontece. O local ali é conhecido como tráfico de drogas. Ela sabia que tinha um mandado de prisão contra ele.

O réu Wellington Jofer Lopes da Silva disse que tinha machucado a cabeça, então, não tinha ido trabalhar. Aí foi almoçar na casa da mãe, viu o bebinho no caminho e parou para conversar está foragido e não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, razão pela qual teve sua revelia decretada. Não conhecia o policial Ricardo Alexandre Neves, e não sabe nada que ele tenha contra o acusado. Foi o policial militar Tavares que disse que não era para liberar ele. Também não conhece Diego Felício Novaes, tenente que determinou sua prisão. Não sabe dizer o motivo pelo qual os policiais disseram que ele é conhecido nos meios policiais como envolvido no tráfico. Não conhecia os outros policiais. Nenhuma droga é dele, nem Eis a prova produzida.

Encerrada a exposição da prova oral convém salientar que a ação penal é procedente, a fim de condenar Wellington Jofer Lopes da Silva, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva quanto ao delito descrito na denúncia.

A existência material do crime de tráfico ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 14), do laudo pericial de constatação prévia (fls. 42/45), do relatório final (fls. 70/75), do laudo químico toxicológico da droga - laudo definitivo (fls. 168/170), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

Ao cabo da instrução, verifica-se que a materialidade do crime restou devidamente demonstrada, nos moldes como apontado pela denúncia. As provas existentes nos autos demonstram ter havido o crime de tráfico.

De se ressaltar, neste interím, que muito embora os entorpecentes encontrados na posse do acusado não tenham sido acondicionados separadamente daqueles encontrados nas proximidades, isso não tem o condão de viciar a prova, neste sentido, o E.

TJSP:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Destinação comercial comprovada. 2. Alegação de quebra de cadeia de custódia consubstanciada na ausência do registro da apreensão do caderno de anotações. Irregularidades na cadeia de custódia que não devem ser analisadas isoladamente, mas sim em conjunto com os demais elementos produzidos ao longo da instrução, cabendo ao magistrado analisar o caso concreto e aferir se a prova é confiável. Precedente do STJ. 3. Hipótese em que, a despeito das irregularidades verificadas no registro da apreensão do caderno, não há elementos que fragilizem o conjunto probatório estruturado em desfavor do acusado. Existência de outras provas que confirmam a responsabilidade do réu. 4. Ilegalidade da busca pessoal.

Afastamento. Configuração de fundadas razões para realização do procedimento de busca pessoal. Precedentes. 5. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal.

Reincidência que deve ser afastada. Condenação pela prática do delito previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas que não gera reincidência. Precedentes do STJ. 6. Tráfico privilegiado afastado em sentença. Possibilidade de aplicação no caso concreto.

Acusado tecnicamente primário. Inexistência de elementos indicativos de seu envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Aplicação do

reduzidor em seu patamar máximo. 7. Imposição do regime fechado em sentença. Acusado primário. Pena aplicada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime aberto. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500666-53.2022.8.26.0616; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

TRÁFICO DE DROGAS - Nulidade - Quebra da cadeia de custódia - Inexistência de indícios de que a droga apreendida tenha sido manipulada ou alterada antes de ser encaminhada à perícia - Alegação que se baseia em mera presunção, que não tem o condão de invalidar a prova realizada - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Condenação mantida. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1513654-77.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)

Não há de se falar, portanto, em invalidade da prova. Aliás, ressalta-se que outros elementos probatórios elucidaram suficientemente que na posse do acusado foram encontradas algumas porções de droga e outras foram localizadas nas proximidades. Assim, não foi demonstrado que o fato de os entorpecentes terem sido juntados prejudicaram a defesa do réu ou possam ter levado a uma conclusão equivocada dos fatos.

Quanto a autoria, a condenação do réu Welington Jofer Lopes da Silva é medida consequencial da prova existente nos autos.

Concluída a descrição da prova oral colhida ao longo da audiência de instrução, ressalto que a versão do réu se revelou isolada nos autos.

Não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos policiais militares em prejudicar o réu. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presente o réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada".

"APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito

de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido".

Estabelecida tal premissa, saliento que, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 07/08), o réu alegou não saber o paradeiro do entorpecente apreendido e também não saber de quem é.

Outrossim, é importante atentar-se para o fato de que as testemunhas policiais militares, que atenderam a ocorrência narraram com riqueza de detalhes como se deu a apreensão da droga.

Ademais, outros elementos que permitem concluir que o réu não apenas trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas para consumo pessoal são a quantidade total da substância apreendida e as condições em que se desenvolveu a ação.

A quantidade total de entorpecente apreendida, correspondente a 106 (cento e seis) invólucros plásticos, contendo em seu interior maconha, com peso líquido total de 108,56 gramas e 181 (cento e oitenta e um) invólucros plásticos, contendo em seu interior "crack", com peso líquido total de 37,19 gramas, segundo o laudo pericial de constatação prévia de substância entorpecentes (fls. 42/45), é superior ao necessário para o consumo imediato de uma única pessoa.

Já a apreensão da importância de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em moeda corrente, figura como mais um indício da prática do tráfico de drogas devido à sua compatibilidade com a venda de algumas porções e a presença de numerário apto a servir como troco de forma a facilitar a transação.

Vale registrar que, embora o réu afirme que o dinheiro seria fruto de seu trabalho, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Quanto às quantias apreendidas nos autos (fls. 14), verifica-se que o réu não demonstrou a origem lícita do dinheiro, tendo sido o numerário apreendido nas mesmas circunstâncias fáticas de parte do entorpecente, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga.

De se ressaltar que as testemunhas de defesa eram parentes e a namorada do acusado, de sorte que seus relatos devem ser observados com reserva, até mesmo por terem afeto pelo acusado.

Fica afastada, também, a desclassificação do delito em comento para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. O fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação. Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

A propósito, está disposto no §2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 as diretrizes que determinam se a droga destina-se a consumo pessoal, a saber:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



Por fim, ainda que o réu não comercializasse os entorpecentes, a conduta de “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” são uma das ações que caracterizam o crime em tela, a saber:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”. (grifo nosso)

Portanto, o simples fato do réu trazer consigo/ter em depósito/guardar as drogas caracteriza a prática pelo réu do delito previsto no artigo 33, caput, da nº 11.343/06.

Em suma, há indícios em abundância (a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento dos entorpecentes, o dinheiro em espécie e a fuga do réu quando seria encaminhado para audiência de custódia) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas guardadas, trazidas e mantidas pelo réu tinham por destino o tráfico, e não o consumo próprio. Ou seja, o réu, em 28 de abril de 2.022, trazia consigo e tinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Constatada a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do fato, passo a dosar a pena do crime, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes (fls. 50/53). As condenações de fls. 50/53 serão valoradas na segunda etapa.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena, sobretudo porque os antecedentes não podem ser utilizados para valorar esta circunstância judicial. A propósito: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. STJ. 3ª Seção. REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077)

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

I) Natureza e quantidade da droga: Sem agravamento na primeira fase, porque as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 112776/MS e HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013 e STF. 2ª Turma. RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014).

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 50/53: o réu possui 3 execuções de pena iniciadas e praticou o delito descrito na denúncia). Desse modo, a exacerbação da pena se faz presente, diante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em 1/5.

Da análise da circunstância agravante, fixo, na segunda fase, a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira etapa

Não há causas de aumento da pena.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tenho que não é caso de aplicá-la.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade. No caso dos autos, as certidões juntadas evidenciam que se trata de acusado reincidente (fls. 50/53).

Assim, mantenho, na terceira fase, a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu é reincidente e foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal)..

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois o réu é reincidente e foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra Wellington Jofer Lopes da Silva, para condená-lo à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá recorrer em liberdade, porquanto persistem os motivos que deram ensejo à prisão preventiva e a presente sentença vem apenas a reforçar os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar. De se ressaltar, neste interim, que o acusado escapou quando preso em flagrante, tendo, inclusive, participado da audiência de modo on-line em apreço ao contraditório e à ampla defesa. O mandado de prisão preventiva só foi cumprido recentemente, o que demonstra que a manutenção da prisão é necessária no caso.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento de todos os bens apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Proceda-se à destruição da droga apreendida, caso remanescente.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Promissao, 11 de novembro de 2022.